

1504622-48.2020.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2052282/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10206176 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1083/20/102 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504622-48.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504622-48.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2052282/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10206176 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1083/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2052282 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1083/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2052282 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 1083/20/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EMANUEL DOS SANTOS RIBEIRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

LEANDRO COSTA CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e §1º, I, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 29 do Código Penal, porque no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 14h00min, na Praça da República, altura do nº 200, República, nesta cidade e comarca da Capital, juntamente com Carlos Emanuel dos Santos Ribeiro e um terceiro indivíduo não

identificado, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para fins de tráfico, 2.210ml de Cloreto de Metileno/Dicloreto, e 574,5 de Tricloroetileno, - vulgarmente conhecidos como "lança-perfume" - substâncias químicas utilizadas na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 06/10) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 209/212).

A denúncia foi recebida (fls. 87/88). Os réus foram devidamente citados (fls. 101 e 104) e apresentaram resposta à acusação (fls. 122). Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 134).

Réu Carlos foi beneficiado com o Acordo de Não Persecução Penal, prosseguindo-se a instrução somente em relação ao réu LEANDRO.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas. Por fim, o acusado LEANDRO foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu LEANDRO nos termos da denúncia. Na primeira fase da dosimetria, requereu o aumento em razão da quantidade de drogas; na segunda fase, requereu o reconhecimento da confissão extrajudicial e da menoridade relativa, decretando-se, por fim, o perdimento dos valores apreendidos. Não se opôs à aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente em parte.

Narra a denúncia que os acusados, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 14h00min, na Praça da República, altura do nº 200, República, nesta cidade e comarca da Capital, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para fins de tráfico, 2.210ml de Cloreto de Metileno/Dicloreto, e 574,5 de Tricloroetileno, - vulgarmente conhecidos como "lança-perfume" - substâncias químicas utilizadas na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 04 e laudo de constatação a fls. 06/10).

Versa a inicial acusatória que, no dia dos fatos, os acusados Carlos Emanuel dos Santos Ribeiro e LEANDRO COSTA CAVALCANTE encontravam-se no local acima descrito em poder de quase 3 litros de substâncias conhecidas como "lança-perfume", que se destinavam a entrega a consumo de terceiros. Destaca-se que guardas municipais que trabalhavam na "Operação Carnaval" pelas imediações da Praça da República avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarda-municipal, um deles deixou o local abandonando uma mochila. Os outros dois indivíduos que permaneceram foram abordados, momento em que a Guarda-municipal encontrou em posse do denunciado Carlos uma mochila, na qual continha noventa e quatro embalagens de "lança-perfume". Com o outro indivíduo abordado, identificado como o denunciado LEANDRO COSTA CAVALCANTE, nada de ilícito foi encontrado, todavia LEANDRO confessou que, embora a mochila estivesse com Carlos, ambos venderiam a droga no carnaval (fls. 17). Outrossim, ressalta-se que, próximo aos acusados, havia a mochila abandonada pelo indivíduo que deixou o local, sendo localizadas em seu interior

setenta e seis embalagens de "lança-perfume". Interrogado na delegacia de polícia, o acusado Carlos optou pelo seu direito constitucional ao silêncio (fls. 13), ao passo que o denunciado LEANDRO confessou a prática do tráfico de entorpecentes em concurso com pessoas (fls. 17), afirmando que ele e Carlos levaram a mochila contendo os vidros de "lança-perfume" e que iriam vender e consumir a droga na festa de carnaval. LEANDRO ainda destacou que Carlos carregava a mochila, mas que os dois estavam juntos para usar e distribuir o "lança-perfume", e que o venderiam por R\$5,00 (cinco reais) cada. Assim, considerando as condições da prisão, a grande quantidade da droga apreendida, a forma de embalagem, bem como a confissão do acusado LEANDRO aos policiais, verifica-se que os acusados traziam consigo a droga cima apontada para fins de tráfico.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 19/22 e 23/24), auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudos de constatação (fls. 06/10) e de exame químico-toxicológico (fls. 209/212), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 17), o acusado LEANDRO disse que foi abordado por guardas civis, junto de Carlos e que ambos estariam levando a mochila, contendo os vidros de lança-perfume, os quais iriam vender e consumir na festa de carnaval; afirma que Carlos carregava a mochila, mas que estavam juntos para usar e distribuir os lança-perfumes, que venderiam por R\$5,00 (cinco reais) cada.

Ouvido em juízo, LEANDRO disse conhecer o corréu do local em que moram. Negou a prática delitativa. Foi ao local apenas para ir ao evento de carnaval. Como conhecia Carlos, aproximou-se dele para pedir um isqueiro, momento em que foram abordados pelos policiais. Carlos estava com uma mochila. Não conhecia o outro rapaz que fugiu. Não confessou a prática delitativa, nem mesmo na Delegacia. Foi abordado somente porque se aproximou de Carlos.

A negativa apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os guardas civis Rafael Vieira Lobato e Iller Martins Paulo, que efetuaram a apreensão das drogas, narraram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 02 e 03), que na data dos fatos, estava em serviço na "Operação Carnaval" pelas imediações da Praça da República quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos depoentes, um desses indivíduos deixou o local abandonando uma mochila. Os outros dois indivíduos que permaneceram foram abordados e encontraram em posse de Carlos uma mochila, que continha em seu interior noventa e quatro embalagens com substância semelhante a "lança-perfume". Com o outro indivíduo abordado, identificado como LEANDRO, nada de ilícito foi encontrado. Próximo aos acusados havia a mochila abandonada pelo indivíduo que deixou o local, sendo localizadas em seu interior setenta e seis embalagens com substância semelhante a "lança-perfume". Diante dos fatos foram conduzidos ao Distrito, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor dos acusados, após a constatação das substâncias entorpecentes.

O guarda civil Rafael, em juízo, adicionou que estavam em patrulhamento pela Operação Carnaval, quando avistaram os réus LEANDRO, Carlos e mais um indivíduo saindo da Estação República. Quando eles visualizaram a Guarda Municipal, um deles abandonou uma mochila e correu; os outros dois também tentaram correr, mas desistiram e foram abordados. Apenas Carlos e o outro indivíduo estavam com mochilas. Conduziram LEANDRO apenas porque ele admitiu que estaria junto na prática do crime de drogas. No local, os detidos disseram que iriam vender os lança-perfume. A mochila foi encontrada com Carlos, mas LEANDRO disse que estava junto na

prática criminosa. Nada disseram sobre consumo. Não viu LEANDRO com mochila, apenas Carlos e o outro indivíduo que fugiu. Só conduziram LEANDRO porque ele assumiu que estava participando. Carlos nada disse sobre LEANDRO estar no tráfico de drogas.

Em juízo, o guarda civil Iller acrescentou que estavam na Operação Carnaval quando visualizaram três pessoas que, ao observarem a equipe, tentaram fugir. Um indivíduo correu e abandonou uma mochila. O outro indivíduo também portava uma mochila e foi abordado. Nas mochilas, foram encontrados frascos com vidros. Indagados informalmente, eles admitiram que os frascos seriam vendidos. Não se recorda se alguma mochila estava com o réu LEANDRO. Recorda-se pouco das versões do réu em razão do lapso temporal, mas acredita que LEANDRO foi conduzido porque disse que estariam juntos.

Consigne-se que os guardas civis metropolitanos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não podem ser sumariamente desprezados. Outrossim, não estão impedidos de realizar prisão em flagrante.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: "A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, §8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. Se qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem condão de inquinar a nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória." (STJ-HC: 129932 SP 2009/0035533-0, Rel.Min. ARNALDO ESTEVES LIMA - DJ 15.12.2009, T5 - QUINTA TURMA.).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos Guardas com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas pelo acusado LEANDRO.

Em que pese o silêncio de Carlos (corrêu beneficiado com acordo de não persecução penal), na fase indiciária LEANDRO confessou a autoria e apontou a sua participação conjunta com CARLOS, em poder do qual os agentes municipais apreenderam a mochila contendo as drogas, que, segundo as afirmações de LEANDRO, seriam destinadas para a distribuição e venda no período de carnaval, pelo valor de R\$5,00, cada unidade.

Não bastasse o quadro incriminador, os guardas municipais ouvidos em Juízo confirmaram a apreensão das substâncias em poder do corrêu CARLOS, com quem LEANDRO foi visto saindo da estação do metro e foram abordados juntos, bem como afirmaram que a condução de LEANDRO se deu pela sua confissão acerca da distribuição dos frascos a terceiros no evento de carnaval à época dos fatos, afastando por completo a negativa de autoria do acusado em Juízo.

Outrossim, interrogado na Delegacia, LEANDRO confessou a prática delitativa, com detalhes.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico, confirmando não somente a qualidade da substância entorpecente apreendida (2.210ml de Cloreto de Metileno/Dicloreto, e 574,5 de Tricloroetileno, - vulgarmente conhecida como "lança-perfume"), mas também a quantidade e a forma de acondicionamento apresentada (frascos), pronta para o imediato consumo de terceiros, típica da atividade de tráfico.

Na espécie, ademais, observa-se que a quantidade de droga e forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não permitiriam sequer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não é o caso de se acolher a tese defensiva acerca de possível ausência de prova da materialidade e por consequência de atipicidade do fato.

O conceito de drogas, para fins da Lei de 11.343/06, está estampado no artigo 66 da Lei de Drogas e consiste em, *ipsis litteris*, "substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998."

Conforme atestado pelo laudo pericial acostado aos autos (fls. 209/212), foram constatadas as substâncias CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e TRICLOROETILENO, classificadas, ao mesmo tempo, segundo o laudo, como substâncias psicotrópicas na Lista B1 e como insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópico na Lista D2, da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017).

Assim, é possível observar que as substâncias encontradas, na forma em que apreendidas, são consideradas como "drogas" para os fins da Lei 11.343/06, de modo que a conduta praticada pelo réu LEANDRO, nas circunstâncias descritas - mormente pela individualização e imediata distribuição de consumo a terceiros - enquadra-se ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas.

À semelhança do ocorrido, cita-se parte do voto do Relator Desembargador Sérgio Ribas, no julgamento da Apelação Criminal nº 1501460-81.69.2018.8.26.0562, que retrata uma situação análoga ao caso em análise:

"Com efeito, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, a substância diclorometano integra a lista B1 (item 21) da Portaria SVS/MS n. 344/98, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - (RDC) n. 103/16 e alterações posteriores, constando do Adendo 6 da lista B1 que "fica proibido o uso humano de CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e de TRICLOROETILENO, por via oral ou inalação".

Concluiu o Desembargador em seu voto que "assim, a comercialização de forma inadequada das referidas substâncias divididas em 50 frascos, enquadra-se na conduta típica prevista no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, em perfeita consonância com o conceito de drogas previsto no art. 66, da Lei 11.343/06."

De mais a mais, mesmo que consideradas as substâncias exclusivamente como insumos, a finalidade do tráfico de drogas estaria caracterizada pela confissão extrajudicial do acusado LEANDRO, bem como pela confissão informal por ocasião de sua abordagem, confirmada em Juízo pelos guardas que participaram da ocorrência, e ainda, conforme já fundamentado acima, pelo fatos das substâncias estarem individualizadas no estado "droga" para o imediato consumo de terceiros.

Oportuno registrar que a conduta do tráfico de drogas na sua figura do "caput" do artigo 33 da Lei de Drogas está suficientemente narrada na denúncia, permitindo a modificação de sua capitulação jurídica sem a necessidade de aditamento.

Em conclusão, muito embora o órgão ministerial tenha descrito na capitulação jurídica o artigo 33, parágrafo 1º, da Lei de Drogas, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, de modo que aplicável na espécie o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal.

Realizado o *distinguishing* do precedente invocado pela defesa, afasta-se a

pretendida absolvição.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) e no artigo 42 da Lei 11.343/06 (a natureza e a quantidade da substância/produto, a personalidade e a conduta social do agente), tem-se que a pena-base deverá ser fixada nos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, há que se reconhecer a atenuante genérica da menoridade relativa para o acusado LEANDRO, a qual, contudo, não produzirá efeito sobre a sanção, uma vez que a circunstância dessa espécie não possui o condão de permitir a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), restando a pena provisória em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, sobretudo pela relevante quantidade de drogas encontradas, reduzo a pena em 1/2 (metade), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada. Como consequência, a pena resta definida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado LEANDRO COSTA CAVALCANTE, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 33, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de Execução.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06; comunique-se após o trânsito em julgado. Não há dinheiro apreendido e vinculado à prática criminosa, restando, pois, prejudicado o pedido formulado pelo órgão ministerial.

O acusado, tendo respondido ao processo solto e em razão da pena aplicada, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a Guia de Recolhimento Definitiva. Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA